논
문

사실을 반영한 저작물에서 창작성 논란과 그 영향:
역사소설, 뉴스, 사진, 3D 프린팅 디지털 모델을 중심으로

설 민 수

수원지방법원 부장판사

Controversies of Originality in Copyright Works Based on Facts: Focused on Historic Novel, News, Photograph, 3D Printing Digital Model

Min-Soo, Seul

Presiding Judge of Suwon District Court.

초록 : 이 글은 사실을 소재로 한 저작물 가운데 역사소설로부터 출발해 기술과 산업의 발전에 따라 저작권의 보호범위로 편입되어온 뉴스, 사진, 마지막으로 다가오는 미래의 산업기술을 대표하는 3D 프린팅의 기초를 이루는 디지털 모델을 중심으로 이러한 사실의 반영이 저작권의 보호대상 여부 및 저작권 침해 판단 인정에 미치는 영향과 그에 따른 대안적 구제방법을 모색하고 한국과 미국의 판례를 비교해 사실과 관련한 저작물의 창작성에 대한 한국법원의 입장을 관련 대법원 판결과 하급심의 최신 판결을 중심으로 살펴본 글이다.

사실을 소재로 하거나 현실을 투영한 저작물 내지 새로운 기술적 발전의 결과물에 대하여 미국과 한국의 저작권 보호범위는 다소 차이를 보이지만 전반적으로 좁은 범위에서 저작권을 인정하고 있다. 특히 상대적으로 한국의 경우는 그 첫 단계인 창작성 인정여부조차도 엄격하게 보는 입장을 취하고 있다. 이러한 입장 차이는 형사적 구제조치가 민사적 구제조치보다 폭넓고 법원의 심리 부담이 이 큰 한국에서 피할 수 없는 선택인지도 모른다.

Abstract : This article deals with copyrighted works based on facts, starting from historic novel to the news, photograph in the order of progress in technologies and it ends with 3D printing digital models which may be important for future industries. This article mainly focuses on how courts have recognized subject matter of copyright and scope of protection in copyrighted works based on facts focused on analysis of precedents in U.S. and Korea comparative, especially Korea courts' stance in recent Supreme Courts and lower court opinion.

Both U.S and Korea courts grant protection of copyrights based on facts whether it is traditional subjects or new technological progress outcome though it may differ slightly in details. Relatively, Korea courts keeps on strict attitudes recognize finding originality which are beginning of infringement. This difference may be justified by Korea's reliance on criminal remedies in copyright infringement and over-burdened court system.

• 논문접수 : 2014. 12. 8. • 심 사 : 2015. 3. 30. • 게재확정 : 2015. 3. 30.

www.kci.go.kr

Ⅰ. 사실을 반영한 저작물에 관련한 창작성 논란과 그 의미

미국의 통상압력에 의하여 1986년 12월 31일 법률 제3916호로 저작권법이 개정되면서 실질적 권리로서의 면모를 갖춘 저작권은 그 후 디지털 문화의 바람을 타고 가장 넓은 생활관계로 침투하고 있고 그 다툼은 도서, 회화, 영화와 같은 전통적 저작물을 넘어 건축물, 안무, 리얼리티 예능프로그램의 포맷 등 다양한 영역으로 확장 중이다.[1] 저작권법 제2조 제1호는 그 보호대상인 저작물을 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로 규정하고 있어 저작물이 되기 위해서는 창작성(originality)을 갖춰야 한다. 대법원은 1995. 11. 14. 선고 94도2238 판결 이래 창작성이란 완전한 독창성을 말하는 것은 아니지만 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방하지 않고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미하며 그 충족을 위해서는 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도여야 한다는 취지로 판시하고 있다.[2]

이러한 창작성은 저작권의 침해 판단의 모든 단계에 영향을 미친다. 우선 저작권자로 주장하는 사람의 작품이 창작성을 갖추지 못하면 저작권법의 보호대상이 되지 못하므로 그 자체로 저작권 침해가 성립하지 않는다.[3] 이는 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물(이하 '2차적 저작물') 역시 마찬가지로 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 하여 새로운 창작성이 부가된다고 인정되는 경우에 원저작물과 구분되는 2차적 저작물로 인정된다.[4] 두 번째로 저작권 침해여부를 판단하는 기준인 실질적 유사성은 모든 부분을 비교하는 것이 아니고 저작자의 창작성이 인정되는 표현부분만이 비교대상이 된다.[5] 마지막으로 저작물의 공정이용 등 저작권의 범위를 제한하는 법리의 적용에 있어 법원은 강한 창작성을 가진 작품일수록 그 적용에 소극적이다.[6] 반대로 침해자의 작품이 강한 창작성을 가진다면 비록 저작권자의 작품이 보호되어야 할 필요성이 있는 경우라도 그 보호범위가 제한된다.[7]

이러한 창작성의 관점에 가장 문제를 던지는 것이 현실세계에서 발생하는 사실(facts)을 재료로 한 저작물이다. 현실에서 연원하는 사실은 일면으로는 새로 만들어 낼 필요 없이 발생한 것을 발견해 보고하면 되기 때문에 인구조사와 같이 막대한 비용과 노력이 투입된 결과물도 사상 또는 감정을 표현한 저작물이라고 볼 수 없다.[8] 이러한 논리를 확장하면 특정한 사실을 가지고 이를 해석하는 시도 또한 사실의 보고로서 창작성이 부정될 수 있다.[9] 하지만 어제 서울에 비가 왔다든지 한국 전쟁이 1950. 6. 25.에 발생했다든지 하는 단순한 사실은 그에 관해 별도로 작성자의 창조적 노력을 필요로 하지 않는 반면

1) 서울중앙지법 2011. 11. 8. 선고 2011가합23960 판결(걸 그룹의 안무), 서울중앙지법 2013. 9. 6. 선고 2013가합23179 판결(펜션건물), 서울고등법원 2014. 7. 3. 선고 2013나54972 판결(리얼리티 예능프로그램).
2) 대법원 2012. 8. 30. 선고 2010다70520,70537 판결(수험서인 재무관리해답집의 창작성을 부정).
3) 대법원 2001. 5. 8. 선고 98다43366 판결.
4) 대법원 2002. 1. 25. 선고 99도863 판결(대중가요를 컴퓨터음악용 곡으로 편곡한 작품).
5) 대법원 1993. 6. 8. 선고 93다3073, 93다3080 판결.
6) Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 496~497 (1984).
7) Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001)(소설 '바람과 함께 사라지다'를 상당히 차용해 흑인의 시각에서 비튼 '사라진 바람'에 대하여 그 창작성에 비추어 패러디로 볼 여지가 있다고 판시).
8) Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 347~8 (1991).
9) Hoehling v. Universal Studios, Inc., 618 F.2d 972, 978~9 (2d Cir. 1980).

www.kci.go.kr

개인적으로 경험한 사실을 옮기거나 역사적 사실의 분석과 추론을 통해 얻어지는 사실은 작성자의 고유한 시각에 의하여 걸러지고 체화되어야 존재하게 된다.[10] 이러한 후자의 사실에 창작성을 인정할지, 인정할 경우 그 범위는 어떻게 보아야 할지는 저작권의 역사에서 지속적 쟁점이 되어왔다.

이 글에서는 사실을 소재로 한 저작물 가운데 저작물의 지위가 처음부터 인정되었던 역사소설로부터 출발해 기술과 산업의 발전에 따라 저작권의 보호범위로 편입되어온 뉴스, 사진, 마지막으로 다가오는 미래의 산업기술을 대표하는 3D 프린팅의 기초를 이루는 디지털 모델을 중심으로 사실이 저작권의 보호대상 여부 및 저작권 침해 판단 인정에 미치는 영향을 한국과 미국의 판례를 비교해 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 역사소설에서 사실과 저작권 침해 판단

1. 역사소설에서 사실과 그 지위

역사적 사실을 소재로 하는 소설이나 희곡 등(이하 '역사소설'로 통칭)에 관한 분쟁이 본격화되기 시작한 것은 20세기 중반 이후이다. 법적으로는 저작권이 일찍부터 발전한 미국과 영국에서 20세기 이전까지만 해도 기존 저작물에 개선을 가한 2차적 저작물에 대한 저작권 침해 인정에 대해 소극적이어서 저작권 분쟁의 대상이 되기 어려웠기 때문이다.[11] 근본적으로는 기존 소설 등을 활용한 영화, 드라마 등 대중을 상대로 한 2차적 저작물에 대한 관련 산업이 20세기 전반기부터 발전한 것이 원인이다.

이렇게 20세기 중반 이후 분쟁이 시작되었지만 역사소설을 둘러싼 분쟁에서 표현이 저작권 보호대상이 되는 반면 소재로서의 역사적 사실 자체는 마치 모든 건물의 구성 부분을 이루는 재료처럼 공중의 영역(public domain)에 속하는 것으로 후세의 저작자들을 위해 이를 소재로 미리 창작한 어느 1인에 의한 저작권의 보호대상이 되지 못한다는 인식은 초기부터 공유되고 있다.[12] 자연스럽게 동일한 역사적 사실을 배경으로 했지만 상당한 차이가 있는 역사소설에 대해 2차적 저작물로 보아 저작권 침해를 인정하는 경우는 상당히 드물다.

물론 초기에만 해도 동일한 역사적 사실을 배경으로 한 역사소설에 대해 그 2차적 저작물로 저작권 침해를 폭넓게 인정한 판결이 미국에서 간혹 나왔다. 대표적 사례가 19세기 중반 스코틀랜드의 Madeleine Smith에 관련한 재판을 소재로 한 연극과 영화에 대한 1936년 Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.[13] 판결이다. 젊은 시절 사귀었던 애인이 약혼자에게 이를 폭로하려하자 애인을 독살했다는 혐의로 기소된 상류사회의 젊은 여성에 대한 재판 실화를 소재로 원고가 창착한 연극을 피고 영화사가 영화화하기 위해 접촉하다가 견해 차이 등으로 영화화가 이루어지지 않은 뒤 동일한 역사적 사실을 배경으로 창작한 소설에 대한 판권을 사들여 영화를 제작한 사실관계를 배경으로 한 위 사건에서 저작권의 법리 발전에 크게 기여했던 Learned Hand 판사는 원고의 연극과 별도의 소설에 기반한 피고의 영화 사이에 무시할 수 없는 차이를 인정하면서도 영화 속 사건의 연속이나 전개

10) Michael Steven Green, "*Copyrighting Facts*", 78 Ind. L.J. 919(2003), p.949
11) Pamela Samuelson, "*The Quest for a Sound Conception of Copyright's Derivative Work Right*", 101 Geo. L.J. 1505(2013), p.1506
12) Echevarria v. Warner Brothers Pictures, 12 F.Supp. 632, 638(S.D. Cal. 1935)(미국 남북전쟁 중 장군들간의 대립에 관한 사건들의 기술이 어느 1인에 의해 독점될 수 없다고 판시)
13) 81 F.2d 49(2d Cir.1936)

www.kci.go.kr

를 이루는 주인공의 성격이나 장면의 세부적 연출이 유사하다는 이유로 침해를 인정했다.[14)]

하지만 소설을 영화화하는데 참여한 각색자들이 모두 원고의 연극을 관람했고 그 중 1인은 대본까지 읽은 독특한 사실관계를 바탕으로 무의식적 표절(unconscious plagiarism)까지 의심되었던[15)] 위와 같은 예외적 사건을 제외하고는 저작권 침해인정에 대하여 분석적 접근 방법이 발달하기 시작한 20세기 중반 이후 미국에서 동일한 역사적 사실을 바탕으로 한 역사소설에 대하여 저작권 침해를 인정한 경우는 찾아보기 힘들다. 구체적 대사나 내용전개 일치하지 않는 사건에서 미국 법원은 소재로 사용된 사실의 동일성이나 그 내용이 문화적 배경으로 작용했음을 들거나 역사적 사실외의 비슷한 장면의 연속은 이와 같은 특정 장르를 구성하기 위한 필수장면(scénes à faire)으로 보아 저작권 침해가 되지 않는다고 판단하는 것이 통상적이다.[16)] 특히 주인공이나 그 주인공을 둘러싼 인물, 사건들이 역사적 사실이나 실화를 차용한 것일 때는 이러한 경향이 강해져 비슷한 내용이나 사건의 연속이 있다고 해도 이를 역사적 사실의 동일성 내지 필수장면으로 보아 저작권 침해를 인정하지 않는다.[17)]

미국보다 뒤늦은 1980년대 이후 저작권이 실질적으로 영향을 미치기 시작한 한국에서 동일한 역사적 사실을 배경으로 한 역사소설에 대한 저작권 침해분쟁에서 법원의 태도는 20세기 중반 이후 미국 법원의 태도와 유사하며 오히려 더 좁게 인정한다고 볼 여지도 있다. 대법원의 태도가 처음으로 드러난 것은 일제 강점기 연해주 이주라는 동일한 역사적 사실을 배경으로 한 소설 천산산맥과 드라마 까레이스키 사이의 저작권 침해를 다룬 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결을 통해서이다. 위 사건에서 원고의 소설은 조명희의 삶을 소재로 하여 일제 강점기에 우리글을 보존하기 위해 연극대본 등을 집필 중 연해주로 탈주하였다가 일본 간첩혐의로 가족과 떨어져 시베리아로 유배되는 남자주인공과 그 배우자인 여자주인공을 중심으로 구성되었고, 드라마는 소작농 출신인 남자주인공과 그의 친구였다가 적으로 변하는 반대역, 그리고 남자주인공과 연인으로 출발해 삼각관계를 이루는 여자주인공을 중심으로 연해주 탈주, 연해주에서의 독립운동과 러시아 혁명당시의 적백교전, 자유시 참변, 스탈린에 의한 강제이주 등을 다루면서 두 저작물 사이에 일제로부터의 탈출, 연해주 정착, 제정 러시아의 붕괴, 볼셰비키 혁명과 내전, 공산정권의 수립, 스탈린의 공포정치라는 역사적 사실에 따른 전개가 공통될 수밖에 없었다. 이에 대하여 대법원은 특정 주제를 다루는데 있어 전형적으로 수반되는 사건이나 배경 등은 아이디어의 영역으로 저작권이 보호하는 창작적 표현형식에 해당하지 않는다는 입장에서 위와 같은 유사점은 공통의 역사적 사실을 소재로 한 데서 나온 것이고 원고가 창작적 표현으로 유사성을 주장한 남녀 한 쌍의 주인공이 눈 속에서 헤매는 모습이나 여자주인공과 러시아 의사와 관계, 강제이주의 상황묘사 역시 저작권의 보호대상이 되지 않는다고 판시했다. 즉, 원고의 역사소설에 표현된 유사장르에서 종전에 볼 수 없었던 장면이 피고의 저작물에서 연

14) *Ibid.* at 55~56.
15) *Ibid.* at 52, 54.
16) Hartwell Harris Beall, "*Can Anyone Own a Piece of the Clock?: the Troublesome Application of Copyright Law to Works of Historical Fiction, Interperation, and Theory*", 42 Emory L.J. 253(1993), pp.282~284.
17) Alexander v. Haley, 460 F.Supp. 40 (S.D.N.Y. 1978)(노예해방기 실화를 소재로 한 소설 뿌리와 남북전쟁 무렵을 소재로 한 소설의 저작권 침해를 부정함), Walker v. Time Life Films, Inc., 784 F.2d 44 (2d Cir.1986)(마약범죄율이 높은 경찰서를 배경으로 한 경찰서를 배경으로 한 자전적 실화와 동일 경찰서를 배경으로 한 영화 사이의 저작권 침해를 부정함)

www.kci.go.kr

속되지 않거나 소설 등에서 구체적으로 표현된 대화나 대사가 유사하지 않은 경우에 서사(narratives)의 유사성만으로는 저작권 침해를 인정하지 않았다.

이러한 경향은 저작권과 관련한 최근의 대법원 판결로 볼 수 있는 선덕여왕의 즉위과정이라는 역사적 사실을 공통 소재로 한 뮤지컬과 드라마 사이의 저작권 침해문제가 쟁점이 된 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다8984 판결에서도 유지되고 있다. 저작권 침해가 인정되기 위한 전제요건인 의거관계가 쟁점인 위 사건에서 원고의 뮤지컬 대본이 출판되거나 공연되지 않아 피고의 접근가능성이 떨어졌기 때문에 사건의 쟁점은 실질적 유사성에 모아졌다. 원심인 서울고등법원 2012. 12. 20. 선고 2012나17150 판결은 탄생의 예언과 비밀, 성장과정에서의 남다름과 고난, 고난극복 후 즉위, 즉위 후 비극적 사랑이라는 극의 전개과정에서 뼈대를 이루는 중심적 사건들, 그리고 등장인물 사이에 갈등구조, 즉 아버지인 진평왕의 강력한 왕권에 힘입어 여자임에도 불구하고 최초로 왕으로 즉위했다는 선덕여왕을 둘러싼 역사적 사실과 다른 미실과의 정치적 대립을 통해 고난을 거쳐 역경을 딛고 성장하는 과정의 서사, 특히 사막에서의 고난, 서역문물과의 접촉 및 이용, 김유신과의 관계 등이 역사적 사실과 다르고 원고의 대본과 유사하다는 점에 주목해 저작권 침해를 인정했다.[18]

이에 대하여 대법원은 원심이 원고 뮤지컬에서 역사적 사실을 넘은 창작적 표현의 영역으로 본 미실과 선덕여왕의 대립이나 미실의 세력으로 인한 진평왕의 무력함 역시 화랑세기에 기재된 신라시대의 중요 군사세력이었던 화랑의 지도자였던 풍월주와 미실이 각종 인적관계를 통해 신라 조정을 지배하고 진지왕을 폐하고 진평왕을 옹립하였다는 미실의 행적이 피고의 드라마에 그대로 투영되고 있는 점에 비추어 동일한 역사적 소재를 바탕으로 한 독자적 창작으로 볼 여지가 있으며 그 구체적 전개방식이 상이한 피고 드라마와 원고 뮤지컬이 유사하다고 볼 수도 없다고 판시함으로써 동일한 역사적 사실에 기한 저작물 사이에 서사의 유사성만으로는 실질적 유사성이 인정되지 않는다는 입장을 유지했다.

2. 역사적 사실의 범위와 저작권 침해 판단에서의 영향

그렇다면 창작성이 부정되는 역사적 사실이란 무엇일까? 법원은 어느 나라에서나 해석의 여지가 개입된 가설로서의 역사적 사실도 창작성이 인정되지 않는다는 입장이다.

대표적인 것이 1937년 미국 영공에서 폭발한 독일 나찌의 비행선 Hindenburg 비행선의 알 수 없는 폭발원인에 대한 추측을 다룬 글에 관련된 1980년 미국 연방 2항소법원의 Hoehling v. Universal City Studios 판결로 폭발이 승무원의 고의적 폭파에서 비롯되었을 수 있다는 기존의 추측을 넘어 원고가 광범위한 조사 끝에 공산당원 여자 친구를 가진 아마추어 사진사인 승무원이 배터리와 플래시 전구 등을 사용해 위 비행선을 폭파했을 것이라는 밝힌 추측을 기초로 하여 발간된 소설에 몇 가지 서브플롯을 더한 영화에 대한 분쟁을 배경으로 한다.[19] 위 사건에서 원고가 핵심적인 자신의 창작으로 주장한 위 폭발원인에 대한 추측과 관련하여 위 법

18) 위 고등법원 판결은 서사와 관련한 유사성만으로 2차적 저작권 침해를 인정한 유일한 판결이다. 기존의 문헌에 많이 언급되는 서울남부지방법원 2004. 3. 18. 선고 2002가합4017 판결이나 전주지방법원 남원지원 2004. 12. 22. 선고 2002가단3038 판결은 모두 동종의 저작물을 대상으로 주인공과 전반적 전개가 동일하고 중요부분에서는 대사나 대화와 관련한 문자적 유사성까지 인정되었다.

19) Hoehling, 618 F.2d at 974~977.

www.kci.go.kr

원은 역사적 사실을 바탕으로 한 추측과 해석 역시 역사적 사실의 일부로 저작권의 보호를 받지 못한다고 판시했다.[20] 대법원도 위 2013다8984 판결에서 미실의 색공과 현실 정치인과의 복잡한 관계가 비록 정사로 인정받지 못하지만 화랑세기라는 역사서에 묘사되고 있다는 점에서 뮤지컬과 드라마에 동시에 나타나는 미실세력과 선덕여왕의 갈등에 대해 실질적 유사성을 가진 것으로 보지 않았는데 이는 화랑세기 상의 미실을 소재로 한 다수의 창작물에서 미실과 선덕여왕의 갈등이 묘사되고 있는 것과 같이 역사적 사실에서 연원한 추측의 하나로 사실과 유사하게 취급한 것으로 볼 수 있다.[21]

그렇다고 역사적 사실에 대한 모든 해석이 저작권이 인정되는 창작의 범위 밖이라고 단정할 수는 없고 몇 가지 사정에 따라 그 결론이 달라진다. 우선 역사적 해석이 이루어진 저작물의 성격에 따라 창작으로 인정되는 범위가 다르다. 원저작물이 역사연구나 역사적 사실의 보고 형태를 띠게 될 경우에는 비록 확립된 역사적 사실과 다르게 추측이나 해석을 통해 해석한 경우로 피고가 원저작물에 의거하더라도 그대로 베낀 경우를 제외하고는 저작권 침해가 인정되기 어렵다.[22] 이 경우 저작권 침해가 인정되는 때는 중요장면의 전개나 인물들의 독특한 성격이 거의 그대로 비교 대상이 되는 원고와 피고의 작품 속에 나타나는 예외적 상황에 그친다.[23] 반대로 원저작물이 소설과 같은 창작물로 역사적 사실을 바탕으로 한 추측이나 구체적 전개가 원고에 의해 최초로 구체화된 경우 피고가 이를 차용했다면 저작권 침해가 인정될 가능성이 높다.[24] 다만 이 경우에도 주된 유사점이 단지 주인공이나 주된 인물 사이에서 일반적 관계의 유사성 정도에 그치거나[25] 원고의 작품에서 유사한 내용이 구체화되지 않은 일반적, 추상적인 것에 불과하고 피고의 작품에서 전개가 보다 구체화되어 있다면 저작권 침해가 인정되지 않는다.[26] 마지막으로는 의거관계가 강할 때 위 침해의 인정 범위가 다소 넓어지는 경향은 저작권 침해가 고의적 행위를 대상으로 하고 있어 피할 수 없다. 즉 원고의 저작물에 대하여 피고가 2차적 저작물 제작 등과 관련하여 교섭 등이 이루어진 경우에는 상대적으로 넓은 범위로의 인정 경향이 강해지고 반대의 경우는 그 범위가 좁아진다.[27]

---

20) Hoehling, 618 F.2d at 978~980.

21) 홍승기, "저작권 침해 요건으로서의 '의거' : 서울고등법원 2012나17150(선덕여왕 사건)을 중심으로", 「계간저작권」 Vol.26 no.3(2013가을, 제103호), 한국저작권위원회, 218면.

22) Hoehling, 618 F.2d 980.

23) Miller v. Universal City Studios, 650 F.2d 1365(5th Cir. 1981)(아동납치 실화에 대한 논픽션 시리즈의 일화나 장면이 텔레비전 드라마에 그대로 재현된 경우).

24) Burgess v. Chase-Riboud, 765 F.Supp. 233 (E.D. Pa. 1991)(미국의 대통령 Jefferson과 그 노예였던 Selly Hammings 사이의 추문이라는 역사적 사실을 바탕으로 한 원고 소설에서 다룬 개별적 역사적 사실을 다룬 에피소드가 피고의 희곡에도 등장한 경우).

25) Chase-Riboud v. Dreamworks, Inc,.987 F. Supp. 1222(C.D. Cal. 1997)(Amistad 노예선의 반란 사건을 소재로 한 원고의 소설과 피고의 영화 사이에 주된 유사점이 주인공 캐릭터 사이의 유사성 정도일 때 저작권 침해를 부정함), 위 2013다8984 판결(선덕여왕과 김유신 사이의 관계에 대한 두 작품의 유사성을 드라마화에서 나오는 일반적 창작으로 보아 저작권 침해를 부정함).

26) 위 2013다8984 판결(원고의 작품에 나온 금관의 꽃이 동로마나 서역의 구체적 영향을 언급하였다고 보기 어려운 반면 피고의 저작물에는 동로마 습득, 정광력 등 동로마의 영향이 구체화된 경우 저작권 침해를 부정함).

27) Burgess, 765 F.Supp. at 240(원저작물인 소설을 구해 자신의 창작 전 읽음), Miller, 650 F.2d at 1367(드라마화 협상이 진행되고 각색자에게 원저작물인 넌픽션을 제작자가 건네줌), 위 2013다8984 판결(원고의 저작물이 미공간, 미실연 작품으로 유포 흔적 없음), Benay v. Warner Bros. Entm't, Inc., 607 F. 3d 620 (9th Cir. 2010)(유사한 소재, 동일한 제목과 일부 유사한 역사적 오류에도 불구하고 미공간 대본에 대하여 유사성을 부정함).

www.kci.go.kr

Ⅲ. 뉴스에 대한 저작권의 보호범위와 관련 쟁점

1. 뉴스에 대한 저작권의 보호 범위

(1) 역사적 발전

19세기 중반까지도 전파의 한계와 비상업적 성격 때문에 저작권 문제가 제기되지 않았던 뉴스에 대한 저작권 보호문제가 제기되기 시작한 것은 19세기 중반 이후 전신이 보급되면서 뉴스의 전달이 빨라지고 신문사 등이 대중을 상대로 한 상업적 경쟁에 나서면서 제일 먼저 보도한 신문사가 경쟁사가 내용을 활용하는 것에 대한 제한을 가하고자 하는 이해관계가 강해지면서였다.[28] 이에 대해 미국 법원은 경쟁사의 뉴스가 적혀 배포되는 전신 자막을 입수해 그 내용을 다시 자신의 전신 자막으로 배포하는 형태의 영업을 하던 피고에 대해 전신 자막에 기재된 뉴스는 저자의 개별적 사상을 표현하는 창작물이라기보다는 모든 사람들이 접근 가능한 사건의 연대기적 기록에 불과해 저작물로 볼 수 없으나 뉴스 자체는 기업적 노력의 산물로 보통법에 따른 부정경쟁방지 청구는 가능하다는 입장에서 접근했다.[29]

그러다가 1909년 미국 저작권법 개정과 함께 뉴스는 저작권의 보호대상으로 명시되었고, 한국에서는 1986. 12. 31. 저작권법이 개정되면서 저작권법이 보호하지 않는 뉴스의 범위가 사실의 전달에 불과한 시사보도로 제한되면서 뉴스는 저작권법의 보호대상으로 편입되었다.[30] 그럼에도 뉴스는 현재에도 법령상으로 저작권의 보호가 가장 제한되는 저작물로 미국이나 한국에서 저작권법이 보도 또는 비평 등의 목적의 뉴스 사용에 있어 정도의 차이는 있지만 공정이용(fair use)의 법리를 통해 뉴스에 대한 저작권 행사를 제한하고 있기 때문이다.[31] 이에 따라 뉴스에 대한 저작권의 보호범위는 공정이용의 범위에 따라 결정되는 경향이 강하다.

최근 저작권에 의한 뉴스의 보호범위가 관심의 대상이 되기 시작한 것은 인터넷의 발전과 함께 뉴스 유통이 빠르게 온라인을 통해 유포·소비되는 형태로 변하고 있으며 주된 뉴스의 유포자가 창작자인 개별 신문사·방송사가 아니라 뉴스를 모아 무료 또는 유료로 뉴스의 헤드라인과 중요 내용만을 전달하는 형태 또는 최종 소비자가 흥미를 가진 뉴스를 중심으로 선별해 공급하는 서비스를 제공하는 뉴스매집자(aggregator)나 포털로 변해가고 있기 때문이다.[32] 그 결과 전통적 뉴스의 창작자인 신문사의 뉴스 공급자로서의 지위가 축소되고 산업 자체에 대한 위기론 역시 증폭되고 있다.[33] 이와 같은 위기에 따라 저작권 등을 통해 보호하려는 요구 역시 강화되면서 그에 관한 분쟁도 보다 표면화되고 있으며 이는 공정이용의 범위가 법령상으로도 한국보다 좁은 미국에서 보다 격렬하게 나타나고 있다.

---

28) Robert Brauneis, "*The Transformation of Originality in the Progressive-Era Debate Over Copyright in News*", 27 Cardozo Arts & Ent. L.J. 321(2009), pp.346~350.

29) Nat'l Tel. News Co. v. Western Union Tel. Co., 119 F. 294, 297, 300-1(7th Cir. 1902), Int'l News Serv. v. Associated Press, 248 U.S. 215(1918).

30) Copyright Act of 1909, ch. 320, § 5(b) 35 Stat. 1076. 구 저작권법(1986. 12. 31. 법률 제3916호로 개정) 제7조 제5호

31) 17 U.S.C. § 107(비판, 평석, 시사보도 등을 목적으로 한 공정이용은 저작권 침해에 해당하지 않는다), 저작권법 제26조(시사보도를 위한 이용), 제27조(시사적인 기사 및 논설의 복제 등), 제28조(공표된 저작물의 인용), 제35조의 3(저작물의 공정한 이용).

32) Brad A. Greenberg, "Tollbooths and Newstands on the Information Superhighway", 20 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 171(2013), pp.173-4. 한국언론진흥재단, "2013 언론수용자의식조사"(2013), 79~80면(포털 뉴스를 매일 이용한 경우가 33.9%로 지상파 종합뉴스의 뒤를 이음) .

33) Brad A. Greenberg, op. cit. p.174.

www.kci.go.kr

(2) 미국

미국 법원은 뉴스기사에 포함된 사실을 추출해 유통시킬 권리가 일반에게 있음은 인정하지만 각 뉴스기사의 문장을 그대로 사용하거나 축약하여 유통시키거나 보도하는 것은 그 자체로 저작권 침해라는 입장을 취하고 있다.[34] 물론 단순한 뉴스 기사의 링크만으로는 저작물의 배포나 전시 등의 권리를 침해하지 않는다.[35] 다만 이러한 판단은 실질적 유사성에 따른 것이기 때문에 대체로 피고가 무단으로 사용한 양의 다과에 따라 판단이 달라질 여지는 있다.[36]

이때 침해 여부를 실질적으로 결정하는 것은 항변인 공정이용에 관한 판단이다. 미국 저작권법 제107조는 공정이용에 관련하여 이용의 목적, 저작물의 성격, 전체 저작물 중 이용된 분량, 이용이 저작물의 시장가치에 미치는 영향이라는 요건을 고려해 판단하도록 규정하고 있지만,[37] 법원의 전반적인 경향은 이용의 목적과 관련하여 기존의 창작 의도와 다른 새로운 요소를 더하는 변형적(transformative) 이용 여부에 따라 판단하고 있다.[38] 뉴스의 무단전재 내지 발췌사용 역시 그 목적이 미국 저작권법 제107조가 공정이용으로 예시한 시사보도, 비판, 평석 등을 위한 것이라도 변형적 이용여부 등 공정이용의 요건 충족여부가 보다 중요하다.[39]

현재까지는 뉴스 내용을 무단 전재 내지 발췌해 그대로 뉴스에 사용한 경우 법원은 침해자의 사용행위가 기존 저작물에 어떠한 가치를 더하지 못한 동일한 목적의 사용일 뿐 아니라 원고 저작물의 시장가치에 부정적이라는 이유로 공정이용을 부정했다.[40] 비판을 위해 뉴스 내용을 사용하는 경우에도 상당한 규모의 상업적 사이트에서 그대로 뉴스 내용을 게재하는 경우에는 요약이나 관련 내용의 링크 게시만으로 충분하다는 점과 신문사의 광고나 온라인 기사를 위한 영업에 악영향을 미친다는 점을 들어 공정이용을 부정했다.[41] 반대로 뉴스 기사의 일부를 블로거가 전체 기사의 링크와 함께 자신의 제3자에 대한 교육목적 사이트에 게시한 경우,[42] 비영리의 토론 사이트에서 사용자가 토론을 위해 연금기금에 관한 기사 전체를 게시한 경우[43]와 같이 비영리 단체가 교육이나 토론, 비평을 위해 게재한 경우에는 공정이용을 긍정한 바 있다.

뉴스의 내용과 달리 뉴스 매집자가 기사원문에 접근하기 위하여 제공하는 헤드라인이나 표제부, 또는 기사의 도입부의 경우에는 법원의 관련 판례는 없으나 원래 미국의 저작권법이 표제부를 보호하지 않는데다가[44] 법원이 이러한 형태의 정보 접근을 보조하는 검색엔진과 같은 도구의 저작권 침해 주장에 적대적 경향을 보이는 점,[45] 전재되는 양에 비추어 침해의 전제인 실질적 유사성을 인정하기 어려운 점을 종합하

34) Wainwright Securities, Inc. v. Wall Street Transcript Corp., 558 F.2d 91, 94(2d Cir. 1977), Nihon Keizai Shimbun, Inc. v. Comline Business Data, Inc., 166 F.3d 65, 69~71(2d Cir. 1999).
35) Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1161~1162(9th Cir. 2007).
36) Nihon, 166 F.3d at 81(6 문장으로 구성된 기사 중 1문장만을 베낀 경우에 유사성을 부정).
37) 17 U.S.C. § 107.
38) Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579 (1994).
39) Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enter., 471 U.S. 539, 561(1985)(보도목적으로 미발표 된 회상록의 상당부분을 인용보도한 경우).
40) Nihon, 166 F.3d at 72~73, Wainwright, 558 F.2d at 94.
41) Los Angeles Times v. Free Republic, 54 U.S.P.Q.2d (BNA) 1453, 1461, 1464(C.D. Cal. 2000).
42) Righthaven LLC v. Realty One Grp., Inc., 96 U.S.P.Q.2d (BNA) 1516, 1518(D. Nev. 2010).
43) Righthaven LLC v. Hoehn, 792 F. Supp. 2d 1138, 1145 (D. Nev. 2011).
44) 37 C.F.R. § 202.1(a).

www.kci.go.kr

면 침해를 인정하기는 어려워 보인다.[46]

(3) 한국

한국의 저작권법은 미국과 달리 제7조 제5호에 '사실의 전달에 불과한 시사보도'를 저작권법의 보호를 받지 못하는 대상으로 명시하고 있어 그 범위가 문제된다. 이에 대해 대법원은 2006. 9. 14. 선고 2004도5350 판결에서 위 입법취지를 저작권법이 사실 자체를 보호하지 않으므로 여러 가지 정보를 정확하고 신속하게 전달하기 위하여 간결하고 정형적인 표현을 사용한 것이라면 창작적 요소가 개입될 여지가 없어 이를 보호대상에서 제외한 것이므로 정치, 경제계의 동향, 연예, 스포츠 소식, 각종 사건이나 사고, 수사나 재판상황, 판결 등에 관한 여러 가지 사실이나 정보를 간결한 문체와 표현 형식을 통해 정리한 경우는 저작권의 보호대상이 되지 않는다고 판시했다. 그 후 하급심은 대체로 수사기관의 수사, 체포, 구속 등에 관련된 기사, 사건의 경과, 관계자 언급, 조사상황을 언급한 기사, 재판과정이나 판결에 관한 관련 사실로 구성되어 있어 뉴스기사의 배열, 형식에 있어 창작성이 발휘될 가능성이 없거나 관계기관의 발표, 자료에 의존하여 간단하게 작성된 기사는 저작물로 인정하지 않는 반면, 취재한 사실을 기초로 작성자의 비판, 전망 등이 표현되어 있거나 인터뷰 등을 기초로 전망 등을 한 경우에는 저작물로 인정하는 입장을 보이고 있다.[47]

무단 전재의 양이나 내용을 기준으로 저작권자의 뉴스와 피고의 침해 의심 뉴스 사이에 실질적 유사성이 인정되는지에 관하여 보면 현재까지 저작권 침해가 인정된 사례는 상당한 수와 양의 기사를 그대로 전재하거나 어휘정도를 변경하고 문장배열을 바꾼 경우에 대하여 실질적 유사성을 인정하고 있는데[48] 그 취지에 비추어 적어도 전체 뉴스에서 상당한 분량의 내용을 그대로 전재한 경우에 한하여 실질적 유사성이 인정될 가능성이 높다.

다음으로 공정이용에 관하여 보면 저작권법이 2011. 12. 2. 법률 제11110호로 개정되면서 제35조의 3에 미국 저작권법 제107조의 규정과 유사하게 ① 영리성 등 이용의 목적과 성격, ② 저작물의 종류 및 용도, ③ 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성, ④ 저작물의 이용이 그 저작물의 현재시장·가치 또는 잠재적 시장·가치를 참작하여 저작물의 통상적 이용방법과 충돌하지 아니하고 저작권자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우 보도 등을 위하여 저작물을 이용할 수 있다는 규정을 두고 있다. 위 규정이 신설되기 전에 미국의 공정이용에 관한 법리가 일반적으로 한국에 적용될 수 있는지에 관해 대법원은 법률규정의 부재를 이유로 부정적인 입장을 보였다.[49]

다만 그 전에도 법원은 개별규정으로 특정행위에 대한 저작권 침해를 부정했는데 뉴스에 대해서 적용될 수 있는 규정은 크게 신문 또는 뉴스통신에 게재된 정치·경제·사회·문화·종교에 대한 시사적인 기사나 논설을 이용금지의 표시가 없는 경우 다른 언론기관이 복제·배포, 방송

45) Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 818~819(9th Cir. 2003)(원래 이미지의 축약판인 섬네일 이미지를 검색엔진이 사용하는 경우를 공정이용으로 판시).

46) Robert Denicola, "*News on the Internet*", 23 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 68(2012), pp.76~85.

47) 서울고등법원 2006. 11. 29. 선고 2006나2355 판결(대법원 2009. 5. 28.선고 2007다354 판결로 저작물 판단부분은 상고기각), 대구지방법원 2006. 12. 28. 선고 2006노2877 판결(위 2004도5350 판결의 환송심 판결), 서울고등법원 2012. 6. 13. 선고 2011나52200 판결.

48) 위 2006나2355 판결, 2006노2877 판결.

49) 대법원 2013. 2. 15. 선고 2011도5835 판결.

www.kci.go.kr

할 수 있도록 한 저작권법 제27조와 보도, 비평 등을 위하여 공표된 저작물을 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있도록 한 저작권법 제28조였다. 실무적으로는 시사문제에 관한 논설에 대하여만 이러한 규정을 두고 있는 일본에 비하여 폭넓은 영역의 기사나 논설에 대하여 적용될 여지가 있지만 이용을 금지하는 표시가 포괄적으로라도 되어 있다면 그 적용이 어려웠던[50] 저작권법 제27조보다는 적용여지가 넓은 저작권법 제28조가 널리 활용되어 왔다. 위 제28조를 해석함에 있어 법원은 '인용'이라는 문언 자체에 크게 구애받지 않고 인용된 부분이 어느 정도의 부종성을 가지고 있으면 인용의 목적, 저작물의 성질, 인용된 내용과 분량, 피인용저작물을 수록한 방법과 형태, 수요자의 일반적 관념, 원저작물에 대한 수요를 대체하는지 여부 등 미국의 공정이용의 법리를 차용하여 비교적 폭넓게 저작권 침해를 부정해 오고 있었다.[51] 이에 따라 저작권법 제35조의3 규정의 신설 이후에도 미공표된 뉴스 등을 제외하고는 뉴스와 관련하여 새롭게 공정이용의 범위가 확대될 것으로 보이지는 않는다.

현재까지는 뉴스 보도기관 사이에 저작권 침해가 문제된 경우는 앞에서 본바와 같이 상당히 많은 분량의 기사나 그 내용을 그대로 전재한 경우였기 때문에 공정이용에 관한 규정의 적용이 쟁점이 된 사례는 거의 없었다. 새롭게 위 저작권법 제35조의 3을 적용한다고 하더라도 미국의 사례에서 보이듯이 비영리 기관 등이 교육목적 등에 사용한 경우 등을 제외한다면 폭넓은 적용은 어려워 보인다.

뉴스 매집자 등이 헤드라인이나 표제부, 또는 기사의 도입부를 링크 등을 위해 사용한 경우는 명시적으로 표제부를 저작권의 대상으로 보는 규정이 없고 서적 제호에 관한 판례가 그 창작성을 부정하고 있는 점[52], 링크에 관하여는 대법원이 검색서비스에서 이미지 사용과 관련하여 그 원본 이미지를 직접 서버에 저장한 경우를 제외하고는 그 원본 이미지 중 특정 객체를 다른 웹페이지로 옮겨 자신의 콘텐츠와 함께 보여주는 인라인 링크에 대해서도 저작권 침해를 부정한 점에[53] 비추어 보면 저작권 침해를 인정하기는 어렵다.

2. 저작권 이외의 방법에 의한 보호

상대적으로 제약이 많은 저작권에 의한 보호보다 최근 주목을 받고 있는 것은 미국 초기 판결에서 언급된 부정경쟁방지법의 논리에 따른 보호이다.

(1) 미국

미국에서 최근 가장 주목받는 것은 전달하는 정보의 가치가 시간적 시의성과 밀접한 가치가 있고 그 정보 수집에 상당한 비용과 노력을 요건으로 하는 최신뉴스(Hot News)의 보호법리이다.[54] 최신뉴스는 창작성이 있어야 보호대상이 되는 저작물과 달리 뉴스가 전달하는 내용의 시의성과 보도기관이 정보수집에 일정한 비용을 지출했다는 요건을 갖추면 되기 때문에 보호범위가 넓어진다.

50) 오승종, 저작권법(박영사 제3판), 616~618면.
51) 대법원 2006. 2. 9. 선고 2005도7793 판결(검색서비스 제공을 위해 이미지를 축소한 썸네일을 사용한 경우를 공정한 관행에 합치된 인용으로 봄).
52) 대법원 1996. 8. 23. 선고 96다273 판결.
53) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결.
54) Jeffrey L. Harrison & Robyn Shelton, "*Deconstructing and Reconstructing Hot News: Toward a Functional Approach*", 34 Cardozo L. Rev. 1649(2013), p.1653.

www.kci.go.kr

최신뉴스 보호는 뉴스에 관한 저작권 개념이 발전하던 초기인 1918년 미국 연방대법원의 International News Service v. Associated Press.[55] 판결에서 시작되었다. 위 판결에서 연방대법원은 제1차 세계대전 당시 특파원을 통해 전쟁뉴스를 취재할 수 없었던 INS 사가 경쟁사인 AP가 특파원을 통해 취재한 뉴스를 AP의 직원 등을 통해 빼내거나 조기 발간된 신문에서 얻어낸 뒤 이에 기초해 자신의 뉴스를 만들어 때로는 AP보다 먼저 뉴스를 배포했던 사안에서 AP의 금지명령 청구를 받아들이면서 개별 뉴스 소비자가 비상업적으로 뉴스를 전파할 권리를 갖는 것과 별개로 뉴스를 만들기 위해 비용을 지출하는 경쟁사업자 사이에 뉴스는 일종의 재산에 준하는 가치를 가지며 INS에게 이러한 영업을 허용하는 것은 비용부담 없이 뉴스를 수집하도록 하여 AP의 정상적 영업활동을 방해하는 것으로 허용될 수 없다고 판시하였다.[56] 그 후 최신뉴스의 보호는 각 주의 개별 부정경쟁방지법에 의한 부정이용(misappropriation)의 법리에 따라 발전하기 시작했는데[57] 적용과정에서 가장 문제가 되었던 것은 비슷한 권리를 규율하는 연방법이 있을 때 이와 충돌하는 주법을 구축(preemption)하는 미국의 법체계에서 저작권법에도 불구하고 주법에 따른 최신뉴스의 보호법리가 적용될 수 있는지 였다. 특히 현재 미국 저작권법에는 저작권법에 의해 보호되는 배타적 권리와 동등한 권리를 보호하는 주법을 구축한다는 명문규정이 있다.[58]

이러한 상황에서 기술발전에 따라 온라인 뉴스와 뉴스매집자에게 고객을 잃게된 전통적인 보도기관이 저작권이 미치지 않는 사실보도 뉴스에 대하여 최신뉴스의 보호에 주목하고 있다. 최신뉴스 보호의 법리가 여전히 유효한지를 확인한 최초의 판결은 인터넷이 막 발전하던 1997년 연방 2항소법원의 Nat'l Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.[59] 판결이다. 당시로서는 혁신적이던 프로농구의 스코어와 관련 정보를 전송하는 호출기기와 서비스를 개발한 Motorola가 방송을 통해 청취한 정보를 직원들로 하여금 컴퓨터에 입력한 뒤 이를 호출기를 통해 전송하자 프로농구협회인 NBA가 저작권 등을 침해하였다고 제기한 소송에서 연방 2항소법원은 저작권법이 충돌을 일으키지 않는 범위 내에서 최신뉴스의 보호를 완전히 구축하지는 않았다면서도 그 보호범위를 ① 원고가 해당정보를 상당한 비용을 들여 창출하거나 수집했을 것, ② 정보는 시의성이 있을 것, ③ 침해자의 정보사용이 일종의 무임승차행위에 해당할 것, ④ 원고와 침해자 사이에 직접적인 경쟁관계에 있을 것, ⑤ 침해자의 정보사용이 원고의 존속에 상당한 위협을 가할 것이라는 5가지 요건을 만족시킨 경우에 한정했다.[60] 위 사건에서는 Motorola와 NBA가 직접적 경쟁관계가 없고 문제된 기기가 NBA의 사업 진행에 지장을 주지 않으며 스코어에 관련 된 정보들은 모든 사람들에게 공개된 정보를 Motorola가 자신의 비용으로 수집한 경우로 위 보호범위에 해당하지 않는다고 판시했다.

가장 최근인 2011년 연방2항소법원이 선고한 Barclays Capital Inc. v. Theflyonthewall.com[61] 판결은 시의성, 무임승차행위, 원고에 의해 제공되는 제품이나 서비스의 존속에 대한 위협

55) 248 U.S. 215 (1918).
56) *Ibid* at 236~240.
57) Metro. Opera Ass'n v. Wagner-Nichols Recorder Corp., 101 N.Y.S.2d 483(N.Y. Sup. Ct. 1950)(뉴욕 주에서 최신뉴스의 보호를 긍정함).
58) 17 U.S.C. §301.
59) 105 F.3d 841(2d Cir. 1997).
60) *Ibid* at 852~854.

www.kci.go.kr

이라는 요소를 보다 중시했고 특히 무임승차행위 여부에 초점을 두었다. 투자은행들의 주식추천보고서를 배포권한이 없는 직원들 또는 제3자 등으로부터 입수한 뒤 이에 기초해 증권 추천과 다른 증시 뉴스를 주식시장 개장 전에 제공하는 유료 가입 웹사이트를 운영하는 피고에 대하여 제1심 법원은 부정이용을 인정했으나 연방 2항소법원은 원고 투자회사들이 보호를 구하는 것은 그들의 전문성과 경험을 통해 특정 주식에 대한 추천을 하는 것인데 피고는 자신의 책임하에 특정 주식에 대한 추천을 하면서 단지 그 근거로 원고 투자회사가 추천을 했다는 전파한 것에 불과해 피고가 원고의 뉴스보도에 무임승차했다고 볼 수 없고 그 수입원을 달리하는 원고와 피고 사이에 원고의 서비스에 대한 위협이 있다고 볼 수도 없다고 판시하였다.[62]

이러한 판결들의 취지는 원고가 뉴스보도 기관으로 직접적으로 피고와 경쟁하고 피고가 원고의 상당한 노력과 비용이 투여된 뉴스 자체를 무단으로 이용한 경우에 가깝지 않는 한 부정이용 자체를 부정하는 쪽이다.[63]

(2) 한국

뉴스보도에 대해서는 비교적 광범위한 저작권 적용배제 규정을 가지고 있고 경쟁자의 상품혼동 또는 표지의 출처혼동 행위를 위주로 발전해 온 부정경쟁방지법의 규정을 가지고 있는 한국에서 위와 같은 행위들이 구체적으로 어떻게 규율되어야 할지는 법률상으로 모호했다. 그러다가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 2013. 7. 30.에 개정되면서 제2조 제1호 차항에 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”가 위법행위로 추가되었고 따라서 저작권법에 의해서는 보호되지 않는 인용보도라도 최초 보도기관이 상당한 투자나 노력을 통해 원래의 뉴스를 만들었고 피고가 이를 별도의 노력을 기울이지 않고 취득해 무임승차식으로 사용하는 행위의 규율 가능성이 높아졌다.

그렇다면 위 입법 적용 이전의 행위는 어떻게 보아야 할 것인가가 문제된다. 대법원은 위 법률 개정을 선도했다고 볼 수 있는 대법원 2010. 8. 15. 2008마1541 결정을 통해 네이버가 제공하는 콘텐츠 중 네이버의 수입원인 배너, 키워드 광고만을 자신이 제공하는 광고로 대체하거나 자신의 광고를 삽입하는 프로그램을 배포하는 피고에 대하여 일종의 부정경쟁행위에 준하는 민법상 불법행위로 보았는데 그 핵심적인 요건으로 경쟁자의 상당한 노력과 투자에 의한 성과물에 대하여 공정한 경쟁질서에 반하는 무단 이용과 그로 인한 경쟁자의 이익침해를 든 바 있다. 이러한 취지는 앞서 본 미국의 판결들이나 새로 개정된 법률규정과 그 요건이 일치하므로 위 법률 개정 전 행위는 민법상 불법행위로 볼 수 있다.

다만 위와 같은 부정경쟁방지법이나 민법상 불법행위의 적용은 저작권법이 순수사실을 바탕으로 시사보도에 대해서는 비교적 광범위한 저작권법의 예외를 적용하므로 어디까지나 강한 시사성을 가진 정보로 원고인 보도기관이 상당한 비용을 들여 보도를 준비한 경우로 동일한 영업을 통해 경쟁하는 보도기관이 보도이전에 미리 자료를 무임승차식으로 취득하여 자신의 보도에 활용한 경우나 출처를 밝히지 않고 무단으로 전재한 경우에 그쳐야 할 것이다.

61) 650 F.3d 876(2d Cir. 2011).
62) *Ibid* at 902, 907.
63) *Ibid* at 905~906. NBA, 105 F.3d at 854.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 사진에 대한 저작권의 보호범위와 관련 쟁점

1. 사진에 대한 저작권의 보호범위

(1) 미국

사진이 본격적으로 발전하기 시작한 19세기 말까지 저작권의 대상이 되는지 의심되었던 가장 큰 사유는 당시 사진의 장점으로 자연 그대로를 인간에 의한 왜곡 없이 기계와 화학물질의 작용을 통해 전달한다는 점이 강조되었던 데다가 주로 건축가, 엔지니어, 군인 등의 사실 보고적 목적에 활용되었고 사진을 촬영하는 사람들이 사진에 관한 교육을 받지 않고 생계 목적으로 촬영을 하고 있어 법적 보호에 대한 이해관계가 크지 않았으며 기존에 저작권에 의해 보호를 받던 회화 등을 창작하던 예술가들이 저작권의 보호범위에 포함시키는데 강한 거부감을 표시했기 때문이다.[64] 이러한 인식은 1865년 저작권법 개정을 통해서 사진이 저작권의 대상이 된 후에도 이어졌고[65] 위와 같은 상황에서 저작권의 보호대상이 되는 사진의 범위를 밝힌 것이 1884년 미국 연방대법원의 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony[66] 판결이다. 저명한 작가였던 오스카 와일드를 당시 최고의 전문 초상사진가였던 원고가 찍은 사진을 피고 회사가 복제해 8만 5,000장 가량 판매했던 위 사건에서 피고 회사는 사진은 기계의 작용에 의하여 사물이나 사람의 모습을 옮겨 놓은 것으로 정확성을 그 가치로 하는 것이어서 저작권의 대상이 될 수 없음에도 이를 허용한 것은 위헌이라는 취지로 주장했는데 연방대법원은 원고가 사진에 나온 오스카 와일드의 의복, 사진 배경인 휘장, 악세서리의 선정과 준비, 신체의 선이 살아나도록 자세, 빛과 음영의 선정, 얼굴 표정을 이끌어 냈다는 점에서 화가의 창작성과 다르지 않다고 보아 원고의 창작성을 인정했지만 일반적 사진의 경우에는 창작성이 인정되지 않을 수 있다고 판시했다.[67]

사진촬영자가 피사체를 사실상 만든 사진의 저작권을 인정한 위 판결 이후 자연물이나 인공적 건물을 그대로 촬영한 사진(straight photograph)의 저작권이 인정되기 시작한 것은 사진작가들 사이에 사진 예술성의 핵심이 대상물에 대한 인위적 조작이 아닌 사진을 통해 영속적 시간 중 의미 있는 순간 포착이라는 인식이 일반화되면서부터다.[68] 물론 그 과정이 순조롭지 않아서 자연물이나 건물을 촬영한 사진의 창작성에 대하여 대상 선정, 순간 포착, 빛의 선정, 주변배경이나 구도 선정 등이 충분히 창작성을 담보한다는 판결들도 있었던 반면[69] 일상적 물건의 카탈로그 사진에 대하여는 창작성을 부정한 경우도 있었다.[70] 일상적 자연물 등을 사실 그대로 촬영한 사진에 대하여 창작성 인정이 확고해 진 것은 1921년 보석상 상표의 카탈로그 사진과 연관된 Jewelers' Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co.[71] 판결의 영향으로 Learned Hand 판사는 아무리 단순한 사진이라도 저자 개인의 영향을 받

64) Teresa M. Bruce, "*In the Language of Pictures : How Copyright Law Fails to Adequately Account for Photography*", 115 W. Va. L. Rev. 93(2012), pp.101~102.
65) Copyright Act Amendment, ch. 126, sec. 1, 13 Stat. 540 (1865).
66) 111 U.S. 53(1884).
67) *Ibid* at 59~60.
68) Teresa M. Bruce, op. cit. pp.106~107.
69) Bolles v. Outing Co., 77 F. 966 (2d Cir. 1897)(요트 사진), Pagano v. Chas. Beseler Co., 234 F. 963 (S.D.N.Y. 1916)(도서관 사진).
70) J.L. Mott Iron Works v. Clow, 82 F. 316 (7th Cir. 1897)(욕조 카탈로그 사진).
71) 274 F. 932 (S.D.N.Y. 1921).

www.kci.go.kr

지 않은 경우는 찾기 어려우며 완벽히 같은 두 사진을 찾을 수 없다고 판시해 사실상 모든 사진에 대하여 창작성을 인정했으며 위 판결은 그 후 미국에서 사진의 창작성을 인정하는 주류적 판결로 인용된다.[72]

현재 미국에서 사진 저작권의 보호는 크게 촬영 각도, 빛과 음영, 노출, 필터에 의한 변형, 현상에서의 테크닉과 같이 사진기의 조작이나 현상과정에서 사진촬영자의 영상을 만들기 위한 기교(rendition)가 적용된 사진, 연어의 도약 순간 촬영과 같은 순간 포착(timing)에 의한 사진, 오스카 와일드의 초상 사진과 같이 피사체 태양이나 배열 자체를 사진촬영자가 조작한 사진의 세 가지로 분류된다.[73] 위 사진들에 대하여 저작권이 보호되는 범위는 기교의 경우는 사진에 적용된 구체적 기교에, 순간 포착은 그 포착된 이미지 자체에 한정되고, 피사체에까지 저작권이 미치는 것은 피사체 태양이나 배열자체를 촬영자가 조작한 경우에 한정된다.[74]

하지만 미국에서도 저작권의 보호를 받지 못하는 사진도 존재한다. 흔히 완전한 모방품(slavish copy)으로 불리는 저자의 창의성의 발현이나 자율성이 없이 기존 저작물 등을 그대로 모사하거나 모방한 회화나 노래의 경우 저작권을 부정했던 논리가 사진에도 적용되는 경우이다.[75] 대표적으로 유럽의 박물관이 소장한 그림을 그대로 찍어 디지털화한 사진의 경우 비록 사진으로 촬영하는 과정에서 촬영자의 렌즈의 조작 등 기술적 적용이 있었다고 하더라도 마치 저작물을 복사기로 복사한 것처럼 창작성이 없어 저작권이 인정되지 않는다.[76] 또한 구글 어스와 같이 인공위성이 촬영한 사진이나 CC 티브이가 촬영한 사진과 같이 인간의 자율성이 전혀 반영되지 않는 사진 역시 마찬가지다.[77]

(2) 한국

사진은 1957년 입법된 저작권법 제2조에서부터 저작물의 하나로 예시되었으나 사진에 대한 저작권 분쟁이 구체화되기 시작한 것은 사진이 상업적으로 널리 사용되기 시작한 1990년대 이후로 가장 기준이 되는 판결은 분쟁 초기에 선고된 대법원 2001. 5. 8. 선고 98다43366 판결이다.

햄 제품 광고용 카탈로그 제작을 위해 햄 제품 자체를 찍은 제품 광고사진과 햄 제품과 양주병, 과일 등을 배치하여 찍은 이미지 광고사진 중 제품 광고사진의 경우는 광고주 측이 준비한 흰 상자 안에 넣고 촬영이 이루어졌고 원고가 광고주가 마음에 드는 사진을 사용할 수 있도록 몇 장의 사진을 더 찍어 넘겨주었으나 광고주가 계약 이외의 광고에 사진을 사용한 것이 문제된 위 사건에서 제1심은 별다른 검토 없이 모든 사진에 대하여 창작성이 있지만 제작과정을 피고 측이 실질적으로 지휘하였다는 이유로 저작권이 피고 측에 귀속된다고 보았고, 항소심은 제품 광고사진의 경우에는 전문사진 작가인 원고가 촬영하여 햄 자체를 충실하게 표현한 사진기술이 적용되었다고 하더라도 창작성이 있다고 볼 수 없는 반면 이미지 광고사진의 경우에는 햄 제품과 배경장식물의 배치 등에 비추어 창작성이 있고 저작권 역시 별도의 특약이 없는 한 원고에게 귀속된다고 판단했다.[78] 이에

72) Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc., 225 F.3d 1068, 1076~1077(9th Cir. 2000).
73) Mannion v. Coors Brewing Co, 377 F. Supp. 2d 444, 452~454(S.D.N.Y. 2005).
74) *Ibid.*
75) Boucicault v. Fox, 3 F. Cas. 977(1862).
76) Bridgeman Art Library, Ltd. v. Corel Corp., 36 F. Supp. 2d 191, 197(S.D.N.Y. 1999).
77) Justin Hughes, "*The Photographer's Copyright - Photograph as Art, Photograph as Database*", 25 Harv. J.L. & Tech. 327(2012), pp.362~374.

www.kci.go.kr

대하여 대법원은 사진저작물에 대하여 창작성이 인정되기 위해서는 피사체의 선정, 구도의 설정, 빛의 방향과 양의 조절, 카메라 각도의 설정, 셔터의 속도, 셔터찬스의 포착, 기타 촬영방법, 현상 및 인화 등의 과정에서 촬영자의 개성과 창조성이 인정되어야 한다고 판시한 뒤 이 사건에서 문제된 제품 광고사진의 경우 햄 제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고하려는 실용적 목적을 위해 원고가 가진 사진기술을 이용한 것에 불과하다는 항소심의 판시를 인용해 상고를 기각했다.

위 항소심과 대법원 판결이 동일하게 강조하고 있는 점은 광고와 같이 실용적 목적을 가진 사진에서 위 이미지 광고사진과 같이 피사체를 사진촬영자가 조작한 경우에는 그 창작성이 인정되지만 피사체가 햄과 같은 특별성이 인정되지 않는 물체라면 촬영자의 영상을 만들기 위한 기교가 특별한 효과를 더하지 않았다면 이는 현실의 복제물로 보아야 할 것이지 창작성을 인정하기 어렵다는 것이다.[79] 즉, 사진의 창작성을 촬영자가 피사체를 조작한 경우, 피사체의 특별함이 인정되는 순간포착의 경우는 창작성을 인정하되 그와 같은 특별함이 없는 경우에는 사진촬영자가 적용하는 구도의 설정, 빛의 방향과 양의 조절, 카메라 각도의 설정, 셔터의 속도, 현상 및 인화 등에서 사진마다 구별할 수 있는 특별한 효과가 나타나지 않는 이상 현실의 사실을 그대로 전달하는 현실의 복제품으로 보는 입장으로 이해할 수 있다.[80] 이러한 입장은 그 이후의 판결에서 유지되고 있는데 대법원은 광고나 교육목적의 실용적 사진이나 영상에 대하여 풍경사진이나 촬영자가 저녁 해와 바다가 보이는 시간대가 보이는 각도와 앉거나 누운 손님을 선택한 찜질방 사진에 대하여는 창작성을 인정한 반면,[81] 단순히 의자가 정리된 음식점 내부만을 촬영한 사진, 고주파를 이용한 수술을 교육하기 위한 촬영에서 촬영대상을 중앙에 위치한 채 근접촬영으로 찍은 치료과정 및 환부 사진에 대하여는 창작성을 부정했다.[82]

위와 같은 대법원의 입장에 대해서는 미국과 비교하여 비판의 목소리가 있지만[83] 사실적·기능적 저작물 전반에 대하여 보호대상 저작물이 요구하는 창작성의 수준을 높임으로써 저작권 침해나 그 구체적 보호범위에 대한 법원의 관여나 판단 범위를 줄이고자 하는 저작권 분야 전반의 대법원의 판결 기류와 유사하다는 점에서 일관성이 있다.[84] 또한 미국과 달리 저작권 침해 일반에 대하여 처벌규정을 두고 있는 한국의 법체계에서 실용적 목적 사진의 창작성 확대는 인터넷을 통한 무단 컨텐츠 사용이 발달한 한국의 현실과 맞물릴 때 저작권법 위반 범법자를 양산할 가능성이 높아 미국과 비교하여 비판하기는 어렵다.[85] 이를 한국만의 현실이라고 볼 수는 없다. 가령, 미국 법원도 상대적으로 광범위한 공익이 인정되어 저작권을 제한할 필요가 있는 뉴스를 목적으로 만든 사진의 경우에는 비

78) 서울지방법원 남부지원 1986. 8. 23. 선고 96가합2171(제1심), 서울고등법원 1998. 7. 22. 선고 96나39570 판결(항소심).
79) 권택수, “사진저작물이 저작권법에 의하여 보호되는 저작물에 해당하기 위한 요건”, 「대법원 판례해설」 제37호(2001), 법원도서관, 341~342면.
80) Justin Hughes, op. cit. pp.476~481.
81) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005도7673 판결(풍경), 대법원 2006. 12. 8. 선고 2005도3130 판결(찜질방 내부).
82) 위 2005도3130 판결(일식집 내부), 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009다44542 판결(치료과정).
83) 이상정, “사진의 저작물성에 대한 일고”, 「계간저작권」 Vol.27 no.1(2014봄, 제105호), 한국저작권위원회, 84~93면.
84) 유영선, “사실적·기능적 저작물의 실질적 유사성 판단방법”, 「기업법·지식재산법의 새로운 지평 진산 김문환선생정년기념 논문집」 제2권(2011), 법문사, 653~655면.
85) 17 U.S.C §506(1)(B)(저작권 침해죄에 180일의 기간 동안 본인의 상업적 이득 또는 사적 재정적 이득 추구를 위해 고의적으로 1,000 달러 이상의 소매가치가 있는 저작물 또는 저작물들을 복제 또는 배포를 요구), 저작권법 제136조 제1항 제1호(저작권 및 인접권리 일반에 대한 침해죄에 대하여 제한을 두지 않고 처벌함).

www.kci.go.kr

록 전문적인 뉴스 사진기자가 구도, 대상선정, 빛과 음영의 선택, 순간 포착, 장소 등을 정한 경우라 하더라도 그 결정을 창작성을 인정할 만한 창의적 과정으로 보지 않는 경향을 보이고 있기 때문이다.[86]

2. 사진에서의 사실과 저작권 침해판단에서의 영향

사진은 사실을 소재로 한 저작물 중 실질적 유사성을 통한 저작권 침해 판단이 가장 문제되는 영역이다. 사진의 경우 무엇이 사실이고 무엇이 표현인지를 구별하는 것이 불가능에 가깝고 특히 자연물이나 인공적 건물을 그대로 촬영한 사진의 경우 이러한 경향은 더욱 심화되기 때문이다.[87]

(1) 미국

상대적으로 넓은 보호범위가 인정되는 사진은 창작성이 인정되는 사진 중에서 사진촬영 단계 및 현상 단계에서 여러 가지 기교가 적용되어 사진이 결과적 이미지에 있어서 초현실적 형태를 가지게 되는 경우이다.[88] 이 경우 사진은 사실상 회화와 크게 구분할 수 없는 표현의 영역에 해당하게 된다.

그 다음으로 보호범위가 넓은 경우는 피사체를 촬영자가 조작하거나 배치한 경우로 앞에서 언급한 바와 같이 피사체에까지 저작권이 미치기 때문으로 볼 수 있다. 가령 모델을 이용한 특정한 개념과 방향을 가지고 촬영한 사진을 동일한 개념으로 유사한 모델을 써 동일 포즈를 이용해 촬영한다면 저작권 침해가 된다.[89] 하지만 이 경우에도 구체적으로 저작권이 보호하지 않는 아이디어를 어디까지로 보느냐에 따라 그 범위가 달라진다. 가령 양복을 입은 직장인이 큰 빌딩의 옥상에서 자살을 하려고 밑의 길거리로 뛰어내리려는 두 장의 사진에서 사진의 유사성이 단지 위와 같이 자살을 하려고 뛰어내리는 직장인과 그 직장인의 옷과 신발의 형태에 불과하고 나머지 구도, 배경, 빛과 음영, 색깔, 각도 등이 다른 경우 위 유사성은 단지 일반적 아이디어인 도시 직장인의 절망이라는 개념의 유사성에 그쳐 실질적 유사성이 인정되지 않게 된다.[90] 반면 유명 농구선수를 돋보이기 위해 구름 낀 하늘을 배경으로 하얀 티셔츠와 운동팬츠를 입게 하고 찍은 사진과 유사한 복장, 액세서리를 하고 유사한 개념으로 모델을 달리해 찍은 사진은 구름 낀 하늘 등의 아이디어적 요소들을 제외하고도 나머지 부분의 유사성으로 인해 실질적 유사성이 인정된 바 있다.[91]

가장 저작권의 범위가 좁은 것이 자연물 등을 별다른 변화를 주지 않고 그대로 촬영한 사진으로 유사성의 원인이 대부분 피사체의 동일성에서 나오기 때문에 무엇이 아이디어이고 표현인지 구분이 쉽지 않기 때문이다.[92] 가령, 유명 골

86) Fitzgerald v. CBS Broadcasting, Inc., 491 F. Supp. 2d 177 (D. Mass. 2007)(악명 높은 조직폭력배 체포과정에 대한 뉴스 사진의 창작성을 부정함).
87) Mannion, 377 F. Supp. 2d at 461.
88) Haberman v. Hustler Magazine, Inc., 626 F. Supp. 201, 211(D. Mass. 1986).
89) Gross v. Seligman, 212 F. 930, 930~931(2d Cir. 1914)(젊은 누드 모델을 이용해 촬영한 사진을 동일모델과 유사한 포즈로 체리가지만을 입에 문채 촬영한 경우 침해를 인정).
90) Kaplan v. Stock Mkt. Photo Agency, Inc., 133 F. Supp. 2d 317, 323-8(S.D.N.Y. 2001). Bill Diodato Photography, LLC v. Kate Spade, LLC. 388 F. Supp. 2d 382(S.D.N.Y. 2005)(사진의 유사성이 여성이 명품 신발과 액세서리를 착용하고 목욕조에 앉아 다리를 보이는 경우에 그치는 경우에 이는 아이디어에 불과하다고 판시함).
91) Mannion, 377 F. Supp. 2d at 461~463.
92) Mannion, 377 F. Supp. 2d at 458.

www.kci.go.kr

프선수가 골프복을 입은 사진을 찍는다면 사진은 아주 특별한 장면을 잡아내지 않는다면 거의 대부분 유사하게 된다.[93] 그 위에 대상이 특정한 자연물이나 물건이라면 유사성이 더욱 증가되기 때문에 실질적 유사성이 인정되는 경우는 더 드물다. 가령 한국의 98다43366 판결과 유사한 사실관계에서 보드카 사진의 창작성을 인정해 한국에서 많이 언급되는 Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc[94] 사건의 경우를 보면 와인병 모양의 보드카 병 사진을 찍기 위해 고용되었던 원고의 사진이 마음에 들지 않자 피고가 별도의 사진작가를 고용해 보드카 사진을 찍었던 사실관계에 대해 최초의 판결에서 피고의 보드카 병과는 별개로 원고 사진의 창작성을 인정했던 9항소법원은 실질적 유사성 문제에 관해서는 대상이 동일하고 그 목적이 유사한 경우에 사진의 저작권 침해가 인정되는 경우는 거의 동일하게 복제된 경우라고 판시한 뒤 조명, 앵글과 음영, 배경 등에 미묘한 차이를 보인다는 이유로 실질적 유사성은 인정하지 않았다.[95]

전반적으로 보면 실질적 유사성 판단에 있어 아이디어로 인정되는 부분을 제외할 때 침해를 주장하는 사진과 원고 사진 사이에 나머지 부분을 볼 때 전체 사진의 결과적 구성의 동등성(compositional-equivalence)에 주목하고 있는 것으로 볼 수 있다.[96] 즉, 두 사진에서 보이는 피사체에 대한 각도, 피사체가 입고 있는 복장의 색깔이나 구성, 배경의 구성에서 원고 사진의 특징적인 부분이 피고 사진에도 그대로 나타나면 침해를 인정하되 이러한 부분이 없다면 이를 인정하지 않는 것이다.

(2) 한국

한국에서는 그동안 사진의 무단 사용 외에 사진의 실질적 유사성을 가지고 문제된 실제 사례가 전무하여 대부분의 논의도 일본의 판례를 중심으로 이루어지고 있는 형편이었다.[97]

그러다가 삼척시에 소재하는 '솔섬'을 2007년 촬영한 영국의 사진작가 마이클 케나의 사진과 유사한 구도를 취한 사진을 광고로 사용한 대한항공과 사이에 저작권 분쟁이 발생하면서 위 문제가 첫 판단을 받게 된다. 원고가 솔섬을 통해 물과 하늘과 나무가 조화를 이루고 있는 앵글이 특징인 위 마이클 케나의 사진에 보인 여러 가지 기교가 그대로 피고가 사용한 사진에 나타난다고 주장한 위 사건에서 1심인 서울중앙지방법원은 2014. 3. 27. 선고 2013가합527718 판결에서 자연물이나 풍경을 특정 계절이나 장소, 시간에 촬영하는 것은 아이디어에 해당하고 동일 자연경관 촬영에서 유사한 콘셉트는 그 자체로 표현을 구성하지 못하며 문제가 된 사진들을 정방형, 장방형으로 구도로 대비되고, 빛의 방향과 촬영시점, 배경인 구름에서의 차이에서 나오는 차이를 들어 실질적 유사성을 부정했다. 항소심인 서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결은 솔섬의 피사체 선정 자체는 창작성을 인정할 수 없고 유사점인 구도의 설정이나 카메라 각도의 설정 역시 자연물인 피사체의 성격상 독특한 창작성을 인정하기 어려우며 실제 케나의 솔섬 이전에도 유사한 작품이 존재하는 점, 나머지 빛의 방향과 양의 조절, 기타 촬영방법, 인화 방법 등의 기교적 측면에 차이가 있는 점, 전체적인 관념과 느낌의 유사성에 따

93) Straus v. DVC Worldwide, Inc., 484 F. Supp. 2d 620, 638(S.D. Tex. 2007)(아놀드 파머의 사진).
94) 225 F.3d 1068(9th Cir. 2000).
95) Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc., 323 F.3d 763 (9th Cir. 2003) 실제로 창작성 유무로 파기한 선행판결에서도 소수의견은 실질적 유사성이 없어 항소를 기각해야 한다는 입장이었다. Ets-Hokin, 225 F.3d at 1082~1083.
96) Teresa M. Bruce, op. cit. pp.139~143.
97) 오승종, op. cit., 1215~1219면.

www.kci.go.kr

른 분석의 경우 원고가 주장한 반영의 색상, 윤곽선의 선명도와 번짐과 같은 요인은 피사체의 동일성과 물에 비친 그림자를 찍는 일반적 촬영기법의 유사성에서 나온 것으로 고려할 것은 아니고 나머지 요소들을 균등하게 보았을 때 수묵화적 느낌과 역동적인 느낌으로 차이를 보이는 점에 비추어 실질적 유사성을 부정했다.

위 두 사진이 모두 솔섬을 중앙에 놓고 렌즈의 장노출 기법을 통해 솔섬이 물에 비친 모습을 중심으로 하늘과 대비한다는 점에서 표현적 유사성이 보이는 것은 부정할 수 없다. 하지만 앞에서 보았듯이 상대적으로 사진의 저작권 범위에 대하여 대법원이 좁은 보호범위를 취하고 있는 점, 미국의 판결 등에서 보이듯이 특정 자연물 등을 그대로 찍은 사진에서의 실질적 유사성은 거의 그대로 복제한 경우 외에는 아주 좁게 인정되고 있다는 점에서 위와 같은 유사성만으로는 저작권 침해를 인정할 정도의 실질적 유사성이 있다 보기는 어렵다.

Ⅴ. 3D 프린팅의 디지털 모델 보호문제

1. 3D 프린팅의 부상과 디지털 모델 보호 문제의 대두

기술적으로 보면 3D 프린팅은 종전의 원재료를 깍아 제품을 만드는 방식과 달리 재료를 결합시켜 제조하는 방식(additive manufacturing)을 말하는 것으로 종전에 종이에 잉크를 한층 덧씌우는 전통적인 인쇄방식과 다르게 플라스틱, 분말, 식품, 세포 등의 소재를 적층시키거나(deposition) 플라스틱 파우더나 액체 중합체, 금속 등의 속재를 접착(binding) 시키는 방식으로 겹겹이(layer) 목적물을 만들어 낼 때까지 인쇄하는 방식으로 최종제품을 만드는 방식이다.[98] 3D 프린터로 목적물을 인쇄시키기 위해서는 그 목적물을 구현한 디지털 모델(digital models)을 입력한 파일을 만들어야 하는데 초기에는 CAD(Computer Aided Design) 프로그램을 이용해 확장자를 .stl로 하는 이런 파일들을 사람이 수작업을 통해 만들었으나 현실에 존재하는 물체나 도면상의 디자인을 읽어들여 파일로 변환시켜주는 3D 스캐너 기술이 급속하게 발전하기 시작하면서 인간의 개입이 적은 자동적 작업 형태로 변모하고 있다.[99] 또한 인간의 수작업에 의한 CAD 파일 작성도 작성자가 CAD 파일 전부를 형성하는 것이 아니라 디지털 모델을 만들기에 용이한 라이브러리 형태로 제공되는 파일들을 조합하는 형태로 무게중심이 이동하고 있다.[100]

이러한 과정에서 저작권의 영역에서 문제되는 이슈 중 하나가 현실의 물건을 스캔하거나 그대로 투영해 제작된 CAD 파일의 보호 문제이다. 다양한 공동작업이나 협업을 요구하는 현대 산업현장의 여건상 CAD 파일은 최초 제작자의 손을 떠나 여러 곳으로 유통될 가능성이 높고 그 경우 CAD 파일을 손에 넣게 된 자는 현재 급속하게 대중화되고 있는 3D 프린터를 사용하여 종전보다 훨씬 쉽게 동일한 제품을 생산할 수 있게 되므로 이러한 CAD 파일에 투여된 노력을 어떻게 보호할지 여부는 향후 3D 프린팅 산업의 진로에도 영향을 미칠 수 있다.

98) Lucas S. Osborn, "*Regulating Three-Dimensional Printing: the Converging Worlds of Bits and Atoms*", 51 San Diego L. Rev. 553(2014), pp. 558~559
99) Haritha Dasari, "*Assessing Copyright Protection and Infringement Issues Involved With 3D Printing and Scanning*", 41 AIPLA Q.J. 279 (2013), pp. 287~288
100) Haritha Dasari, op. cit., p.294

www.kci.go.kr

2. 미국

3D 프린팅 관련 CAD 파일에 관한 저작권 분쟁에 관련된 것은 아니지만 현재까지 선례로 작용하고 있는 판결은 쟁점이 실존하는 물건들을 디자인에 이용한 CAD 파일 전반과 관련 있는 연방 제10항소법원의 2008년 Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.[101] 판결이다.

위 사건에서 원고는 영화, 광고, 게임 등에서 사용되는 3D 디지털 모델을 전문으로 공급하는 회사로서 토요다 자동차 광고 등에서 향후 기존의 사진을 대신해 사용될 자동차들의 디지털 3D 프레임 제작을 의뢰받았는데 그 제작과정은 측정테이프로 자동차를 덮은 뒤 이를 컴퓨터 소프트웨어로 각 점의 수치를 연결해 대강의 모델을 만들고 다시 원고의 직원들이 그 후 장시간의 수작업을 통해 실제 자동차들과 3D 디지털 모델이 일치하도록 가다듬는 3단계로 이루어졌다.[102] 토요다와 원고 회사 사이에 그 후 디지털 모델의 라이선스에 관한 분쟁 속에 원고 회사가 저작권 침해를 주장한 사건에서 제1심 법원은 위 3D 디지털 모델이 기존에 토요다의 자동차 디자이너들이 했던 작업을 통해 형상화된 디자인을 그대로 옮겨 놓았을 뿐 별도의 창작성을 가지지 못해 저작권의 보호를 받지 않는다는 토요다의 주장을 인정했고 10항소법원 역시 이러한 디지털 모델을 기존의 물건과 독자적으로 창조된 별개의 창작물로 볼 수 없다고 보고 항소를 기각했다.[103] 이러한 과정에서 10항소법원은 사진에서 완전한 모방품에 대하여 저작권을 부정한 판결을 인용하면서 원고 회사의 디지털 모델은 이러한 사진과 유사하게 일체의 변형 없이 토요다의 자동차의 형태를 충실히 묘사한데 그쳤다고 판시함으로써 위 모델링 과정에서 원고의 직원들이 한 각종 작업의 창작성에 대하여 이를 기존의 사실을 그대로 묘사한 다른 예술작품이나 사진들과는 명백하게 차이를 두는 입장을 드러냈다.[104]

비록 위 판결에서는 현실의 물체에 변형을 가한 디지털 모델에 대해서는 저작권의 개입여지를 열어뒀지만 적어도 현실의 물체를 그대로 전이시키거나 일부 변형한데 불과한 디지털 모델은 위 판결이 밝힌 원칙에 의하면 비록 그 과정에서 아무리 많은 노력이 투입되었다고 하더라도 저작권의 보호대상이 되지 못하게 된다. 위 판결에 대해서는 3D 프린터에 사용된 디지털 모델과 같이 기술적 발전에 기초한 물건에 대한 창작성은 기존 물건을 그대로 묘사했다고 하더라도 스스로 만들어 낸 이상 기존의 창작성과 달리 보아야 한다는 비판적 입장이 일부 전개되고 있지만[105] 위 판결과 다른 입장을 보인 판결은 현재까지 나오지 않고 있다.

3. 한국

한국에서 3D 프린팅에 사용되는 기존 물건들을 묘사하거나 사용한 디지털 모델인 CAD 파일의 창작성이나 그 저작권 대상성 여부가 다투어진 적은 없다. 다만 다음과 같은 사정에 비추어 보면 기존 물건을 그대로 투영한 CAD 파일의 창작성 인정범위는 상당히 좁을 것이다.

우선 기존의 저작물 중 이에 가장 디지털 모델에 유사한 것은 저작권법 제4조 제8호가 도형저작물의 하나로 예시하고 있는 '설계도'로 볼

101) 528 F.3d 1258(10th Cir. 2008).
102) *Ibid.* at 1260~1261.
103) *Ibid.* at 1264.
104) *Ibid.* at 1267~1268.
105) Edward Lee, "*Digital Originality*", 14 Vand. J. Ent. & Tech. L. 919(2012), pp.948~950.

www.kci.go.kr

수 있다. 위 설계도에 관하여 현재까지 기준이 되는 판례인 2005. 1. 27. 선고 2002도965 판결에서 대법원은 도형저작물의 경우 예술성의 표현보다는 기능이나 실용적인 사상의 표현을 주된 목적으로 하는 이른바 기능적 저작물로서, 기능적 저작물은 그 표현하고자 하는 기능 또는 실용적인 사상이 속하는 분야에서의 일반적인 표현방법, 규격 또는 그 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 이해의 편의성 등에 의하여 그 표현이 제한되는 경우가 많으므로 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않을 가능성이 크므로, 기술 구성의 차이에 따라 달라진 표현에 대하여 동일한 기능을 달리 표현하였다는 사정만으로 그 창작성을 인정할 수는 없고 창조적 개성이 드러나 있는지 여부를 별도로 판단하여야 한다고 판시해 설계도의 저작권 범위를 좁게 본 바 있다. 특히 위 사건에서 쟁점이 된 배치도면에서 구체적인 연결관계가 입찰시방서의 도면에 의하여 도시되어 있으므로 작성자의 창작성이 발휘될 수 있는 부분은 각 장비의 구체적인 모양이나 위치 배열인데 배선, 장비연결, 단자를 표시한 내용이 기계설계 분야에서 통상적으로 사용하는 다이어그램에 불과하고 그 실물모양 역시 CAD 프로그램에서 정한 것이라고 보아 창작성을 부정했다. 그 후의 하급심 역시 위 판결과 유사한 관점에서 독자적 창안이 아닌 그 구체적 구현방식이 이미 과업지침서 등에 의하여 사전에 정해진 기계·설비 등의 설계도면에 대해서 창작성을 부정하고 있다.[106] 즉 원래 그 구체적 형상이 현실세계에 존재해 사전에 정해져 있는 이상 이를 표현한 설계도에 아무리 많은 노력이 투여되었다고 하더라도 이는 작성자의 창조적 개성이 반영되었다고 보지 않는 위 판시에 따른다면 현실의 사물을 실제로 반영한 디지털 모델을 만드는 과정에서 각종 수치조절 등에 아무리 많은 노력이 투여되었다고 하더라도 저작권을 인정할 수 없게 될 것이다.

다음으로 비록 지도에 관한 것이지만 현실에 존재하는 사물 중 일부를 3D로 표현한 지도에 대하여 법원은 이러한 경우 그 창작성의 범위를 좁게 보아야 하며 이 경우 주요 구조물의 본래 현상에 가깝게 입체적인 형태로 표시하되 지도의 목적에 맞도록 단순화한 것이어서 창작성이 없다고 본 바 있다.[107] 실제 현실에 존재하는 물건을 스캔하거나 다른 방식으로 디지털 모델을 만드는 과정에서 그 목적에 따라 일부가 변형된다고 하더라도 위와 같은 판시에 따르면 그 역시 창작성의 발휘로 인정되기는 어려워 보인다.

마지막으로 전통적 저작물 중 디지털 모델과 유사하게 사실이 가장 많이 투영된 현실에 존재하는 물체를 촬영한 상업적 목적의 사진에 관하여 앞에서 본 바와 같이 한국법원은 순간 포착 등 별도의 요인이 존재하지 않는 한 부분적 기교의 적용만으로 창작성이 있다고 보지 않는 입장을 유지하고 있다. 같은 논리가 디지털 모델에도 그대로 적용될 수 있다.

V. 글을 마치며

지금까지 살펴본 바와 같이 사실을 소재로 하거나 현실을 투영한 저작물 내지 새로운 기술적 발전의 결과물에 대하여 미국과 한국의 저작권 보호범위는 다소 차이를 보이지만 전반적으로 좁은 범위에서 저작권을 인정하고 있다. 특히 한국의 경우는 그 첫 단계인 창작성 인정여부조차도 엄격하게 보는 입장을 취하고 있다. 이러한 입장 차이는 앞에서 언급한 바 있듯이 형사

106) 서울중앙지방법원 2011. 9. 23. 선고 2009가합84030 판결.
107) 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009도14298 판결, 서울중앙지방법원 2009. 5. 15. 선고 2008가합36201 판결.

www.kci.go.kr

적 구제조치가 민사적 구제조치보다 폭넓은 한국 현실에서 피할 수 없는 선택일 수도 있다.

이러한 과정에서 사실과 표현을 분리하여 그 보호를 달리하고 있는 저작권은 기술의 발전에 따라 사실과 표현이 혼용되면서 보다 형해화되는 모습을 보이고 있다. 앞으로 한국법원의 과제는 이러한 사실과 표현의 구체적 경계선을 보다 주의깊게 형성하는 것일 것이며 그 과정에서 공중과 산업의 이익을 조화시키는 일 또한 중요한 도전이 될 것이다.

주제어 : 창작성, 사실, 의거, 역사소설, 실질적 유사성, 뉴스, 최신뉴스 보호법리, 사진, 3D 프린팅 디지털 모델

Key-word : originality, facts, derivation, historic novel, substantial similarity, news, hot news doctrine, photograph, 3D printing digital model

www.kci.go.kr